

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Vito Francesco Nettis | Presidente rel. |
| 2) dott. Enrico Sigfrido Dedola | Consigliere |
| 3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2856 dell'anno 2021

TRA

Parte_1

assistita e difesa dall'avv. Nicola Nanni

- appellante -

E

CP_

assistito e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari

- appellato -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 9 ottobre 2020, *Parte_1* esponeva:

che aveva lavorato alle dipendenze di *CP_2*

che il 13 settembre 2017 la Pragma aveva sottoscritto con *Organizzazione_1* contratto di affitto di ramo d'azienda denominato *Organizzazione_2*, cui essa ricorrente era addetta;

che il contratto d'affitto prevedeva che non erano compresi nel ramo d'azienda i debiti maturati alla data della cessione e che, per quanto riguardava i dipendenti del ramo d'azienda, la cedente garantiva che tutti erano stati regolarmente retribuiti ed erano stati effettuati tutti gli accantonamenti obbligatori in ordine al TFR;

che il 15.09.2017 aveva sottoscritto accordo di conciliazione in sede sindacale con *CP_2* che, tra l'altro, aveva riconosciuto il debito per TFR (€11.970,77) e per le mensilità di agosto e ratei settembre 2017, ratei 13, ratei 14, ferie e permessi;

che, stante l'inadempimento di *CP_2* al pagamento delle mensilità di agosto e settembre 2017, aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 5050/18, non opposto;

che con sentenza n. 647 del 12.09.2018 il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento di *CP_2* (fallimento n. 633/18);

che in data 12 novembre 2018 l'affittuaria (che nel frattempo aveva cambiato la denominazione in *Org_3*

[...] e che successivamente sarebbe stata incorporata nella *Org_1* *Controparte_3*

aveva esercitato il recesso dal contratto d'affitto ai sensi dell'art. 79 L.F., e l'azienda era stata retrocessa al fallimento;

che, per accordi intercorsi tra il fallimento e l'ex affittuaria, quest'ultima aveva continuato a gestire in via provvisoria il ramo d'azienda;

che in accoglimento di apposita sua istanza, con provvedimento assunto all'udienza del 26 febbraio 2019 era stata ammessa al passivo per l'importo complessivo di €14.384,08, di cui €11.970,77 a titolo di TFR e €2.413,31, a titolo di retribuzioni per i mesi di agosto e settembre 2017 e ferie non godute;

che aveva chiesto al Fondo di Garanzia ^{CP-} il pagamento del TFR e delle ultime mensilità ex art. 2 d.lgs. 80/92;

che la domanda era stata accolta con provvedimenti ^{CP-} del 25 giugno 2019 e i relativi importi, al netto delle ritenute di legge, erano stati effettivamente erogati;

che, nel frattempo, il fallimento Pragma, dopo apposita stima e procedura d'asta, aveva ceduto, con atto pubblico, il ramo d'azienda all'ex affittuaria (la cui denominazione era cambiata in ^{Org_3} ;

che l'art. 3 dell'atto pubblico prevedeva: "Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 105, 4 comma, del R.D. 267/1942 è esclusa la responsabilità della parte cessionaria per i debiti relativi al ramo d'azienda ceduta sorti prima del 13.09.2017";

che, ai sensi dell'art. 4, la cessionaria era subentrata nei contratti di lavoro relativi ai dipendenti della società fallita;

che con provvedimento del 20 dicembre 2019 l'^{CP-} le aveva richiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di TFR e crediti di lavoro per complessivi €.10.277,39 con la seguente motivazione: "TFR e crediti diversi per Fondo garanzia non esigibile poiché si tratta di passaggio per affitto di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c."

che la pretesa dell'^{CP-} era illegittima;

che, invero, l'originario contratto di affitto del ramo d'azienda del 13.09.2017 era stato stipulato quando la cedente ^{CP_2} era ancora in bonis;

che, tuttavia, l'affittuaria ^{Org_3} in data 12.11.2018 aveva retroceduto il ramo d'azienda al fallimento ai sensi dell'art. 79 LF, con la conseguenza che i lavoratori erano tornati in forza alla società fallita;

che essa era attualmente dipendente della ^{Controparte_3} a socio unico (incorporante della ^{Org_3} in forza dell'atto di cessione del ramo d'azienda del 05 settembre 2019, intercorso tra il ^{Organizzazione_4} e ^{Org_3} ;

che lo stesso ^{CP-} con messaggio 2272/2019, in caso di trasferimento di azienda aveva chiarito: “In termini riassuntivi, l’ordinamento non prevede, in tali ipotesi, l’obbligo per il cessionario in bonis di accollarsi i debiti del cedente verso i dipendenti e, di conseguenza, in assenza dell’intervento del Fondo di Garanzia, i crediti dei lavoratori rimarrebbero privi di tutela, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 80/987/CEE (oggi 2008/94/CE). Nella prospettiva del superamento della predetta antinomia – che ha alimentato un notevole contenzioso – ed in una ottica di legittimo contemperamento delle diverse esigenze sottese alla fattispecie di cui trattasi e di effettiva realizzazione delle tutele dei lavoratori, si ritiene che il TFR (maturato nei confronti del cedente) possa essere considerato esigibile alla data del trasferimento. Ciò, del resto, in coerenza con quanto disposto dall’art. 368, comma 4, lett. D) del decreto legislativo n. 14 del 2019. Detta soluzione è rispettosa anche della direttiva 2001/23/CE, la quale, all’articolo 5, paragrafo 2, lett. A), prevede che nel caso di trasferimento d’azienda attuato da impresa insolvente (anche assoggettata a procedura non liquidatoria), uno Stato membro può disporre che i crediti vantati nei confronti del cedente non siano trasferiti al cessionario, purché la procedura concorsuale alla quale è assoggettato il datore di lavoro cedente dia titolo ad una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987/CEE”;

che, pertanto, quando, come nella specie, il cedente è impresa soggetta a procedura concorsuale, il Fondo di Garanzia gestito e amministrato da ^{CP-} ha il dovere e l’obbligo di intervenire e tutelare il lavoratore/creditore.

2. Tanto esposto, chiedeva che fosse dichiarata “l’illegittimità e l’infondatezza del provvedimento di [...] ^{CP_4}

^{CP_4} datati 20.12.2019, e di ogni richiesta di ripetizione delle somme già erogate dal Fondo di Garanzia ^{CP-} .

3. Nel contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale, con sentenza n. 3074/2021 pubblicata il 31 marzo 2021 rigettava il ricorso.

Rilevava il primo giudice:

che <<alla data del 12.9.2018 (di dichiarazione di fallimento della ^{CP_2} e alla data del 6.2.2019 (di ammissione allo stato passivo), il rapporto di lavoro della ricorrente non era cessato, ma, per effetto

dell'affitto del ramo d'azienda risalente al 18.9.17, era proseguito con la società *Organizzazione_1*

[...] di conseguenza non poteva fondatamente pretendersi l'intervento del Fondo di Garanzia, posto che il Tfr non era esigibile ed il credito doveva ritenersi trasferito in capo alla cessionaria>>;

che <<non può neppure essere valorizzata la circostanza per cui in data 12.11.18 la società affittuaria aveva manifestato l'intenzione di recedere dal contratto di affitto di azienda, perché per ammissione di parte ricorrente tale recesso non si è mai concretizzato, avendo la cessionaria proseguito nel gestire l'azienda sino a quando ne ha ottenuto l'aggiudicazione>>;

che l'art. 105 comma 4 del R.D. 267/1042 – secondo cui “Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento” - inverte la regola sancita dall'art 2560 comma 2, c.c. secondo cui normalmente il cessionario di azienda risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta se risultanti dalle scritture contabili, ma non ha nulla a che vedere con l'art 2112 comma 2, c.c. che sancisce, a prescindere dalle risultanze contabili, la responsabilità solidale del cessionario di azienda per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, le cui deroghe sono invece contenute nell'art 47 della legge 428/90, nel caso di specie non applicato>>.

4. Con ricorso del 20 settembre 2021, la *Pt_1* interponeva appello.

Resisteva l'*CP_*

5. Con il primo motivo, l'appellante contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui il recesso dal contratto di affitto da parte della *Org_3* non sarebbe stato mai attuato.

Deduce la parte:

che aveva esibito la pec con cui l'affittuaria esercitava il recesso ex art. 79 L.F.;

che è indiscutibile che il ramo d'azienda fu messo in vendita;

che <<poiché aggiudicatario all'esito della procedura di vendita avrebbe potuto essere anche società diversa dalla precedente affittuaria, è ovvio che la vendita del ramo d'azienda, il subentro

dell'aggiudicatario/acquirente nei rapporti di lavoro e nei contratti commerciali in essere, non poteva che partire da un presupposto: il precedente contratto d'affitto (che aveva scadenza al settembre 2020) era stato risolto, ed il fallimento era rientrato nella piena disponibilità del ramo d'azienda. Sotto altro profilo, l'aver precisato che il "perimetro" del ramo d'azienda messo in vendita non includeva debiti e crediti sorti alla data del 13 settembre 2017 ma includeva la responsabilità del cessionario per debiti per operazioni commerciali "effettuate successivamente alla data del 13 settembre 2017", altro non poteva significare che questo: il precedente contratto d'affitto del 13 settembre 2017 era stato risolto, ed il fallimento metteva in vendita per l'appunto il ramo d'azienda con tutti i debiti e crediti sorti a partire dal 13 settembre 2017 (diversamente, essi sarebbero stati di esclusiva spettanza dell'affittuario", senza che il cessionario dovesse accollarsi alcunché)>>;

che <<il ramo d'azienda è stato venduto nell'ambito di procedura competitiva dal *Organizzazione_4* (cedente) a *Org_3* (cessionaria)>>;

che <<il ramo d'azienda includeva dieci dipendenti addetti al ramo d'azienda, tra i quali l'appellante>>;

che <<ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'atto di vendita "per effetto della cessione la parte cessionaria subentra nei contratti di lavoro>>;

che <<aggiudicataria all'esito della procedura competitiva, e conseguentemente acquirente dell'azienda, è risultata essere la *Org_3* già *Organizzazione_1* ex affittuaria dell'azienda>>;

che <<il credito per TFR (e per le ultime due mensilità) della lavoratrice al 13.09.2017 era consacrato in apposito accordo di conciliazione sottoscritto in sede sindacale>>;

che <<all'art. 3, ultimo comma, dell'atto di vendita era precisato che "ai sensi dell'art. 105, 4 comma, del R.D. 267/1942, è esclusa la responsabilità della parte cessionaria per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta sorti prima del 13 settembre 2017">>;

che l'^{CP} aveva sostenuto in prime cure che "accantonato presso l'ultima azienda tutto il TFR maturato sino al 31.12.2019 per l'importo complessivo di euro 16.245,00, che attiene, com'è chiaramente evincibile

all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente a favore della Pragma, della **Org_1** e della società **[...]**
Organizzazione_5 ”;

che, invece, <<dalla certificazione unica 2021 (affidente l'anno 2020) rilasciata da **Controparte_3**
[...] alla lavoratrice...contrariamente a quanto dedotto da **CP_** risulta da questo documento che il TFR
accantonato non è di euro 16.245,00 ma di soli euro 5.487,33 (e cioè solo quello maturato dopo il settembre
2017)>>.

6. Con il secondo motivo, l'appellante deduce che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, ai debiti
da lavoro pregressi si applica l'art. 105 comma 4, che costituisce nuova ed ulteriore eccezione all'articolo
2112 c.c.

7. Entrambi i motivi - esaminabili congiuntamente perché connessi – sono fondati.

È agli atti la pec con cui l'affittuaria ha comunicato il 12 novembre 2018 il recesso ex art. 79 L.F. dal contratto
di affitto.

Il testo, inequivoco, è il seguente:

*Oggetto: Fallimento n°633/21018 - **CP_2** Contratto di affitto di ramo d'azienda del 13.09.2017 (Atto
Notaio **Per_1** Rep.1225): comunicazione di recesso*

Spett.le Curatore Avv. Francesco Piselli,

*facciamo seguito ai colloqui intercorsi per comunicarle di volerci avvalere della facoltà di recesso unilaterale,
e dunque di recedere, dal contratto di affitto di ramo di azienda di cui all'oggetto, facoltà prevista dalla
integrazione al contratto stipulata con atto del notaio **Persona_2** del 12.03.2018 (Rep. 1716).*

*Il recesso dal contratto di affitto di ramo d'azienda, in via meramente subordinata, per il solo caso di
inefficacia per qualsivoglia ragione del recesso operato in virtù della norma contrattuale, viene comunque
disposto ai sensi dell'art. 79 L.F.*

*Per effetto dell'esercitato recesso l'azienda oggetto del contratto viene messa a disposizione della curatela
del **Org_4** .*

In data 5 settembre 2019 è stato sottoscritto tra l'avv. Francesco Piselli, in qualità di Curatore del **Org_4** [...] n. 633/2018 e la **Organizzazione_3** la cessione dell'azienda della società fallita a seguito di aggiudicazione in data 16 luglio 2019 conseguente a procedura competitiva.

Il contratto prevedeva, tra l'altro:

“Le parti convengono che ai sensi dell'art. 105, 4 comma, del R.D. 267/1942, è esclusa la responsabilità della parte cessionaria per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta sorti prima del 13 settembre 2017”.

“Per effetto della cessione del ramo d'azienda la parte cessionaria subentra nei contratti di lavoro relativi ai dipendenti”.

Dunque, è incontestabile, sulla base dei predetti atti, che la **Pt_1** (come altri lavoratori) ha lavorato continuativamente dal 13 settembre 2017 per **Org_3** nel ramo d'azienda originariamente appartenente alla società fallita **CP_2** poi ceduto in affitto alla **Org_6** e da quest'ultima definitivamente acquistato dal fallimento con atto del 5 settembre 2019.

Resta da stabilire se la **Org_6** sia tenuta o no al pagamento del TFR maturato dalla **Pt_1** nel periodo in cui è stato alle dipendenze della **CP_2**

In fattispecie analoga (dichiarazione di fallimento nel corso di un rapporto d'affitto, successivamente prorogato, seguito da cessione d'azienda in favore dell'ex affittuario) Cass. 24691/2021 ha affermato:

<<Il testo del comma 5 della L. n. 428 del 1990, art. 47, interpretato conformemente alla norma comunitaria di cui reca attuazione nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia Europea, consente pianamente di includere tutte le procedure fallimentari nell'ambito delle imprese che possono disapplicare l'art. 2112 c.c.

La disposizione normativa recita: "5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il

mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 c.c., salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante".

In simmetria con il paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva comunitaria 2001/23/CE, il suddetto comma 5 consente solamente alle procedure aventi finalità liquidatorie del patrimonio la possibilità di disapplicare l'art. 2112 c.c.>>.

A nulla rileva (diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale) che, di fatto, l'appellante abbia continuato a prestare servizio presso la stessa struttura.

Cessato l'affitto (circostanza che può ritenersi pacifica sia per il contenuto della mail sia per la stipula stessa del contratto di cessione, che postula la riacquisita piena disponibilità dell'azienda da parte del fallimento, quale parte cedente e, comunque, il mutamento del titolo del possesso da parte della cessionaria, da affitto a proprietà) e trasferita l'azienda nell'ambito di una procedura fallimentare, la **Org_6**, cessionario non era tenuta al pagamento dei diritti maturati dalla **Pt_1** per l'attività resa in favore della fallita **CP_2** essendo inapplicabile il disposto di cui all'art. 2112 c.c.

D'altra parte, come ben rimarcato dall'appellante, lo stesso **CP-** era giunta alle medesime conclusioni con il messaggio 2272/2019 (il cui contenuto è stato sopra riportato al punto 1).

7. In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato che la **Pt_1** non è tenuta a restituire all'**CP-** le somme alla stessa Luogo già erogate dal Fondo di Garanzia.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 20 settembre 2021, da **Parte_1** nei confronti dell'**CP-** avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 31 marzo 2021 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, dichiara che la **Pt_1** non è tenuta a restituire all'**CP-** la somma di €.10.277,39 percepita dal Fondo di Garanzia.

Condanna l'**CP-** al pagamento, in favore della **Pt_1**, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, per ciascun grado, in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2023

Il Presidente estensore

dott. Vito Francesco Nettis